

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、別居している実弟Aとの間で、自己が所有するX市内の土地（以下「本件土地」という。）を代金3000万円で売却する売買契約を締結し、Aから代金全額の支払を受けたものの、本件土地の所有権移転登記は未了のままであった。

そこで、甲は、自己が経営する会社の資金繰りのため、自らが保管していた本件土地の登記済証を利用し、事情を知らないBに対して、本件土地に抵当権を設定するので、それを担保に1000万円を融資してほしい旨申し入れたところ、Bは、これを了承した。数日後、甲は、Bから1000万円の融資を受けた上、Aに無断で本件土地の抵当権設定登記を完了した。

X市の土木部長である乙は、本件土地を乙個人として購入したいと考え、甲に対して、その旨を申し入れた。甲は、乙に対して、本件土地は既にAに売却済みであるが、登記名義は自分に残っているので、代金2000万円で売却してもよい旨を伝えたところ、乙は、これを了承した。そして、乙は、Y市内に時価700万円の農地（以下「本件農地」という。）を所有していたことから、本件土地の購入資金を調達するため、それまでにX市発注の公共工事の受注に際して、土木部長として便宜を図ってきた建築業を営むCに対して、本件農地を時価で買い取ってほしい旨を依頼した。Cは、本件農地にはそれまで買手が全く見付からず、乙が苦勞していることを知りながら、かねてX市発注の公共工事の受注に際して乙が有利な取り計らいをしてくれたことに対する謝礼の趣旨に加え、時価であれば損をすることもないと考えて、乙の依頼を了承した。そして、Cは、乙と本件農地の売買契約を締結した上で、乙に現金700万円を手渡した。

その後、甲は、Aに無断で乙と本件土地の売買契約を締結し、乙から代金全額の支払を受けた上、本件土地の所有権が売買により乙に移転した旨の登記を完了した。

【記述】

ア. 甲がAに無断で本件土地に抵当権を設定し、その旨の登記を完了したことについては、甲に横領罪が成立するが、Aは甲の実弟であるので、告訴がなければ公訴を提起することができない。

イ. 甲が本件土地をAに無断で乙に売却し、所有権移転登記を完了したことについては、それ以前に甲がAに無断で本件土地に抵当権を設定し、その旨の登記を完了したことによって、犯罪の成立は妨げられないので、甲に横領罪が成立する。

ウ. 乙は、本件農地を時価でCに売却したのであるから、乙がCから交付を受けた現金700万円は通常の経済取引に基づく不動産の購入代金であり、不正な利益としての賄賂には当たらないので、乙に収賄罪（收受）は成立しない。

エ. 仮に、乙が、Cに対して、時価を超える1000万円で本件農地を購入するよう依頼したが、Cはこの依頼を拒否した場合、収賄罪と贈賄罪は対向犯として必要的共犯の関係にあるので、乙に収賄罪（要求）は成立しない。

オ. 乙は、甲から本件土地が既にAに売却済みであることを知らされながら、Aに無断で本件土地を購入し、所有権移転登記を完了したのであるから、乙に横領罪の共同正犯が成立する。

No.436

犯罪の成否②

正答率

共通H30-20

正解

ア 1

イ 1

ウ 2

エ 2

オ 2

17%

ア 正しい ★

244条2項、255条により、本記述は正しい。

まず、甲がAに無断で本件土地に抵当権を設定し、その旨の登記を完了した行為について、横領罪(252条1項)が成立するか問題となる。不動産を売却した後、移転登記が完了していない間に、売主が第三者に対する債務の担保として抵当権設定登記を了する行為は横領罪に当たる(最決平21.3.26参照)。よって、甲には、横領罪が成立する。

次に、Aは甲の実弟であるので、甲の横領罪は告訴がなければ公訴を提起することができないか問題となる。244条の規定は、この章の罪(第38章 横領の罪)について準用する(255条)。前項に規定する親族(配偶者、直系血族又は同居の親族)以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(244条2項)。本記述では、Aは、甲の実弟であるから、配偶者又は直系血族に当たらない親族であり、かつ、甲とは同居していない。よって、甲には、255条が準用する244条2項が準用され、甲には横領罪が成立するが、告訴がなければ公訴を提起することができない。

イ 正しい

本記述では、本件不動産につき、先行する抵当権の設定行為により既に横領罪が成立していることから、その後の無断売却行為について別途横領罪は成立しないのではないか問題となる。最大判平15.4.23(百選Ⅱ69事件)は、「売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができるというべきであり、先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」としている。その理由として、判例は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしきままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、受託者が、その後、その不動産につき、ほしきままに売却等による所有権移転行為を行いその旨の登記を了したときは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をしたものにほかならない」ということを挙げている。

ウ 誤っている

本記述では、乙は本件農地の買手が全く見付からず苦勞していたところ、Cがこれまでの乙の有利な取り計らいの謝礼の趣旨で、これを買取っていることから、時価による買取りであっても、Cの本件農地の買取りによる換金の利益は賄賂に当たるのではないかが問題となる。最決平24.10.15は、本記述と類似の事案において、「被告人Aは……県知事であって、同県が発注する建設工事に関して上記の権限を有していたものであり、その実弟である被告人Bが代表取締役を務めるCにおいて、本件土地を早期に売却し、売買代金を会社再建の費用等に充てる必要性があったにもかかわらず、思うようにこれを売却できずにいる状況の中で、被告人両名が共謀の上、同県が発注した……工事受注の謝礼の趣旨の下に、Fに本件土地を買取ってもらい代金の支払を受けたというのであって、このような事実関係の下においては、本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても、本件土地の売買による換金の利益は、被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、賄賂はいやしくも人の需要・欲望を充たすに足りる一切の利益を包含する(大判明44.5.19)ところ、本件事実関係の下では、本件土地を換金して金員を取得することそれ自体が、被告人らの需要・欲望を充たすに足りる利益であるということを示している。

エ 誤っている

本記述では、収賄罪（要求）は被要求者が要求に応じなければ成立しないのかが問題となる。大判昭9.11.26は、公務員がその職務に関し賄賂を要求するときは、その要求行為自体において汚職の事実が存在するものであるから、被要求者がこれに応じる意思がないため、要求者がその目的を達することができない場合においても、賄賂要求罪の成立を認めることに妨げはないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、賄賂の要求とは、相手方に対して、認識し得る状態において、賄賂の交付を求める意思表示をすることをいい、相手方が、それを承諾することは要しないし、意思表示を認識したかを問わないということを挙げている。

オ 誤っている

本記述では、本件土地が既にAに売却済みであることを知りながら、Aに無断で甲より本件土地を購入し、所有権移転登記を完了した乙に、横領罪の共同正犯が成立するかが問題となる。最判昭31.6.26は、甲がその所有にかかる不動産を第三者に売却し所有権を移転したるも未だその旨の登記を了しない場合において、乙がその情を知りながら甲に対する債権の代物弁済として右不動産の所有権を取得しその旨の登記をしたという事案において、「被告人乙は、被告人甲に対する……債権に基づきその代物弁済として……本件不動産の所有権移転登記を受けその所有権を取得したというのであるから代物弁済という民法上の原因によつて本件不動産所有権を適法に取得したのであつて、被告人甲の横領行為とは法律上別個独立の関係である。されば本件においてたとえ被告人乙が『前記の事実を良く知りながら』右所有権の移転登記を受けたとしても、これをもつて直ちに横領の共犯と認めることはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、民法理論において、単純悪意者は民法177条の「第三者」に当たり、民法上有効に所有権を取得することができる と解されていることとの整合性を図ることができるということを挙げている。

